

1500292-06.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066127/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 23498709 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2066127 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN WILSON MARÇAL BARNABE

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500292-06.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-06.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066127/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 23498709 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2066127 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN WILSON MARÇAL BARNABE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

RUAN WILSON MARÇAL BARNABE foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de março de 2.022, na rua Professor Isaac Portal Roldan, quadra 06, Jardim Ouro Verde, nesta cidade, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 696,49 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 88), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 93/94.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 10 de maio de 2.022 (fls. 100/102). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 136 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 140/143).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 147/186, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- a confissão informal não é elemento de prova válido; 3)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 4)- o réu não foi avistado realizando comércio de drogas e disse que estava na casa de sua prima, e não na rua; 5)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 15 e pelo laudo pericial de fls. 62/65 (noventa e três porções de maconha com peso de 696,49 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Interrogado na polícia, o réu afirmou que não portava droga. Foram os policiais quem a colocaram. Estava em sua casa e viu uma viatura. Os policiais lhe pediram dinheiro, droga e arma. Tinha uma bicicleta em casa. Os policiais passaram a dizer que se tratava de item roubado. Foi levado à delegacia por causa da bicicleta, e não em razão da droga. Em sua casa, havia a quantia de R\$ 236,00, que pertencia a sua prima, moradora do mesmo imóvel. (fls. 06).

Em juízo, a testemunha Jurandyr Ferreira da Silva Júnior, policial militar, disse que realizava patrulhamento na rua em que o fato ocorreu. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. Em certo momento, viu o réu com uma bicicleta. Ao ver a viatura, ele tentou se evadir e foi abordado. O acusado portava uma mochila, na qual foram encontradas um tijolo e algumas porções de maconha, além de valor em dinheiro. O réu confessou que a bicicleta era produto de roubo. Não havia queixa em relação à bicicleta, razão pela qual ela foi liberada e restituída à genitora do acusado. De imediato, ele já confirmou estar "na venda". Depois, porém, como de praxe, o acusado disse ao delegado que os policiais militares o forjaram. O dinheiro estava "picado", ou seja, fracionado em várias cédulas. O acusado indicou a residência de uma prima ou outra parente, dizendo que ali estava alojado. A familiar em questão autorizou a entrada da polícia no imóvel para retirada dos documentos dele.

A testemunha Hugo Gomes Ribeiro, também policial militar, afirmou que realizava patrulhamento no bairro Jardim Ouro Verde. O bairro tem alta incidência do tráfico. O réu avistou a equipe policial e começou a se evadir, de forma acelerada, em uma bicicleta. A abordagem foi realizada em frente à casa da prima dele. O acusado informou que ali residia com sua prima. Na mochila que ele portava, havia um tijolo e três porções de maconha, além de pouco mais de duzentos reais. Ele confessou que a droga lhe pertencia e que a bicicleta era produto de furto. Na delegacia, a bicicleta foi liberada para a mãe do acusado, pois não havia boletim de ocorrência de furto a ela relacionada. O acusado afirmou que a droga era sua e que a estava vendendo. Ele nada disse sobre a origem do dinheiro. O numerário estava em notas diversas. A prima do réu autorizou a entrada da polícia na casa, para que se pudesse pegar seus documentos. Não foram feitas buscas no imóvel. Em seguida, o acusado foi encaminhado para a delegacia.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que droga não lhe pertencia. Não estava de bicicleta e nem tinha mochila. Sofreu um acidente em data recente. Sua mãe mora num sítio. Ficou abrigado na casa de sua prima para fazer tratamentos. Não sabe se o dinheiro veio das mãos do policial ou se era de sua prima. Os policiais não pediram autorização à sua prima para adentrar no imóvel.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

É certo que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico. A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais o réu estava na posse de uma mochila, na qual contida a droga e o dinheiro apreendidos.

Não vinga o argumento de que os depoimentos dos policiais, quando isolados, não se prestam à condenação.

Afinal, por qual razão dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em juízo, para afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação ?

Ademais, as afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Veja-se ainda que, embora o acusado tenha dito que estava no imóvel de sua prima e que não portava nenhum entorpecente, não a arrolou como testemunha para demonstrar o alegado.

A inércia, no ponto em questão, é sintomática.

Portanto, não colhe a tese de que a prova é frágil.

De outro lado, dúvida inexistente de que o acusado estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, o réu foi flagrado portando quantidade de maconha mais do que suficiente para comprovação de destinação ao comércio espúrio, bem como dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico.

Destarte, o fato ilícito deve ser enquadrado na moldura do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

Nesse sentido:

“Portanto, para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitiva, às circunstâncias nas quais estava o agente. In casu, foram arrecadadas 3,60g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, sendo certo que a aludida droga estava separada em vinte e uma porções, propícias ao comércio.” (TJ-MG, Apelação Criminal 10481100114174001, Des. Rubens Gabriel Soares – Relator).

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a transporte e a traga consigo (conforme descrito na

denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Impõe-se, pois, a condenação do réu por tráfico.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não tem antecedentes criminais (fls. 26/31).

Deste modo, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena nele estabelecida. Com efeito, a par da primariedade e ausência de antecedentes, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

Acrescente-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena.

Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado.

Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 - A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de

'atividade criminosa'. 2 - Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se

afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 - Recurso provido, para reduzir a pena

em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-

62.2013.8.26.0071).

Aliás, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou em caso parelho:

"Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito, essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Da leitura da decisão transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. O Tribunal de origem destacou que a paciente 'se dedicava à atividade ilícita de modo habitual e reiterado, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e que das circunstâncias em que foi surpreendida pelos policiais militares, isto é, por volta de 1h25 (...) tudo a indicar que não era principiante e fazia do comércio ilícito seu meio de vida, emergindo inegável, portanto, o seu envolvimento com atividades criminosas, notadamente com traficantes de maior porte, seus fornecedores ou patrões." Contudo, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a provar a afirmativa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, especialmente quando se observa que o Parquet somente arrolou como testemunhas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ora, a configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos e não de meras ilações, sem correspondência fática. O envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, como apontou a decisão atacada, pressupõe que o agente, no mínimo, pratica ou praticou diversos atos ou, ao menos, está inserido em grupo/organização direcionada ao crime. Entretanto, o ônus de provar tais elementos que afastam a redutora é da acusação, não cabendo ao magistrado colher elementos extraprocessuais para imputar uma reprimenda mais severa, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, o caso trata de condenação pelo tráfico de 7,67 (sete gramas e

sessenta e sete decigramas) de maconha, mais 4,5 (quatro gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, ou seja, não se trata de quantia vultosa como afirmado no acórdão proferido pelo TJSP. Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de traficante primária e não há nenhuma indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas." (Habeas Corpus n. 137458/SP, j. 29/09/2016).

É certo que, no caso, a apreensão recaiu sobre 696,49 gramas de maconha, quantidade que não pode ser considerada pequena.

No entanto, segundo entendimento dos Tribunais Superiores (STJ e STF), a mera alusão à quantidade de entorpecente, dissociada de qualquer outra circunstância, não é hábil a caracterizar dedicação a atividade criminosa.

Cabível, pois, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Considerando, no entanto, que restou apreendida quantidade razoável de entorpecente, a redução da pena deve se dar no patamar de um terço, resultando em três anos e nove meses de reclusão, mais trezentos e setenta e cinco dias-multa.

Não se invoca o patamar mínimo de diminuição (um sexto) porque, no caso, a apreensão recaiu sobre maconha, droga cuja natureza não é tão nociva à saúde dos usuários e à sociedade como um todo se comparada a outras espécies.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada e a ausência de antecedentes criminais, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas não serem das mais elevadas, entende-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Ruan Wilson Marçal Barnabe como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar trezentos e setenta e cinco dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro

apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante a pena imposta, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

Bauru, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA